

0001749-74.2022.8.26.0586

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Flavio Roberto de Carvalho

Comarca: São Roque

Foro: Foro de São Roque

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/12/2022

... ter em depósito, trazer consigo para fins de tráfico, sem autorização legal ou regulamentar, a droga proibida, basta para integrar a figura criminosa do tráfico ilícito. Vender, em tema de entorpecente, é uma das condutas típicas, e não "conditio sine qua non" de delito de tráfico ilícito. Nesse sentido: "Apelação - Tráfico de entorpecentes - Materialidade ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Roque

Foro de São Roque

1ª Vara Criminal

Av. John Fitzgerald Kennedy, Sao Roque-SP - cep 18130-510

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0001749-74.2022.8.26.0586 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0001749-74.2022.8.26.0586

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 2224341/2021 - Delegacia de Polícia de Araçariguama

Autor:

A Justiça Publica

Réu:

WELLINGTON FERREIRA BORGES

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Flavio Roberto de Carvalho

Vistos.

JOSE LUIS BERNARDO, LUCAS OLIVEIRA ROBLES, DIEGO DOS SANTOS RIBEIRO, WELLINGTON FERREIRA BORGES, FELIPE DE OLIVEIRA SOARES, JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO, JOYCE RODRIGUES DOS REIS qualificado nos autos foram denunciados pelo Ministério Público, pela prática do crime tipificado no artigo 35, "caput" da lei 11343/06 porque nas circunstâncias de tempo e lugar descritas na inicial, associaram-se para praticarem o delito de trafico de drogas.

Consta ainda que LUCAS OLIVEIRA ROBLES, DIEGO DOS SANTOS RIBEIRO, WELLINGTON FERREIRA BORGES, FELIPE DE OLIVEIRA SOARES, JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO, JOYCE RODRIGUES DOS REIS qualificado nos autos foram denunciados pelo Ministério Público, pela prática do crime tipificado no artigo 33, "caput" da lei 11343/06 porque nas circunstâncias de tempo e lugar descritas na inicial, guardavam e mantinham em depósito para fins de traficância 171 porções de cocaína, 30 de crack, 01 de maconha, drogas que determinam dependência física e psíquica, sendo certo que agia sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Consta ainda que JOSE LUIS BERNARDO, LUCAS OLIVEIRA ROBLES, DIEGO DOS SANTOS RIBEIRO, WELLINGTON FERREIRA BORGES, FELIPE DE OLIVEIRA SOARES, JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO, JOYCE RODRIGUES DOS REIS qualificado nos autos foram denunciados pelo Ministério Público, pela prática do crime tipificado no artigo 33, "caput" da lei 11343/06 porque nas circunstâncias de tempo e lugar descritas na inicial, guardavam e mantinham em depósito para fins de traficância 18 porções de cocaína, drogas que determinam dependência física e psíquica, sendo certo que agia sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Consta ainda que JOSE LUIS BERNARDO, LUCAS OLIVEIRA ROBLES, DIEGO DOS SANTOS RIBEIRO, WELLINGTON FERREIRA BORGES, FELIPE DE OLIVEIRA SOARES, JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO, JOYCE RODRIGUES DOS REIS qualificado nos autos foram denunciados pelo Ministério Público, pela prática do crime tipificado no artigo 33, "caput" da lei 11343/06 porque nas circunstâncias de tempo e lugar descritas na inicial, guardavam e mantinham em depósito para fins de traficância 01 tijolo de maconha, drogas que determinam dependência física e psíquica, sendo certo que agia sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Acompanhou a denúncia o inquérito policial (fls.01/398) e documentos, onde se destaca: relatório de investigação (fls.04/48,93/94,226/228), boletim de ocorrência (fls.49/52,74/77,86/88,128/138,145/149,157/165,173/182,184/185,200/207,209/212,263/267,270/283,286/287,290/292,294/303), laudo celular (fls.55/68,192/195,471/484,547/560,580/585, 587/589), relatório de chamadas (fls.101/126), auto de exibição e apreensão (fls.186/187,268,284/285,293), auto de reconhecimento fotográfico (fls.196/198), exame químico toxicológico (fls.468/470,538/540,561/563). A denúncia foi recebida em 20 de outubro de 2021 (fls.440/443), os réus foram citados e ofertaram Defesas (fls.610/631,666/669,676/687,688,689/691,700/702,734/736), realizando a instrução com o desmembramento do feito em relação a Wellington (fls.878/880), com posterior designação de audiência onde foi deferida a prova emprestada e colhido o interrogatório do acusado. (fls.926)

Em memoriais finais, o Ministério Público insistiu na condenação com fixação da pena acima do mínimo diante da quantidade de drogas apreendida, se opondo a aplicação do redutor. (fls.932/951)

A Defesa insistiu na improcedência sustentando a inocência do réu, com tese de fragilidade probatória. (fls.963/967)

É o relatório. DECIDO.

A materialidade está comprovada a sociedade pelo relatório de investigação (fls.04/48,93/94,226/228), boletim de ocorrência (fls.49/52,74/77,86/88,128/138,145/149,157/165,173/182,184/185,200/207,209/212,263/267,270/283,286/287,290/292,294/303), laudo celular (fls.55/68,192/195,471/484,547/560,580/585, 587/589), relatório de chamadas (fls.101/126), auto de exibição e apreensão (fls.186/187,268,284/285,293), auto de reconhecimento fotográfico (fls.196/198), exame químico toxicológico (fls.468/470,538/540,561/563), corroborado pela prova oral coligida.

Quanto a autoria, o acusado Wellington disse ter as contas bancárias para enviar para os demais, que depositavam dinheiro e entregava em mãos. Ganhava R\$ 400,00 por quinzena e não sabe quanto o terceiro ganhava. Conhecia o Jose Luis e passava as contas para ele. Estava em situação difícil mas sabia que era algo errado. Conheceu Jose pois morou na cidade de Araçariguama em 2018. Não reconhece o apelido de docinho, mas era conhecido como gordo.

Raphael Szabo disse que receberam algumas denúncias a respeito de um indivíduo de vulgo cachaça que residia na Rua Roraima, e que estaria vendendo drogas na viela ao

lado da casa, e trabalhava para Lucas, e a droga que sobrava ele armazenava na residência. A denuncia não trazia dados, mas apenas que era irmão de uma moça que prenderam tempo atrás, e que analisando seria Jenifer. Fizeram a abordagem de cachaça, e estava com uma porção de maconha, e autorizou a entrada, e mostrou outras porções, e acabou preso, e autorizou o manuseio do aparelho celular, e viram que no dia anterior ele levou drogas a Alex vulgo Veinho, . Chacara era o Jose Luiz Bernardo, e também prenderam Veinho, e o Jose Luiz assumiu a autoria e Alex negou os fatos, e já tinham feito outras prisões em flagrante na região. Jenifer foi obrigada a vender drogas para Nicolas em virtude de dividas de Jose Luis Bernardo com o mesmo. Com a autorização judicial foi feito a perícia do celular, e identificaram cabeçudo que seria Lucas, o qual quando era menor foi detido varias vezes por drogas, e já havia a identificação dele, e nas conversas apareciam contato dele com os demais, inclusive para reabastecimento. Também tinham conversas com Da Nike, que era o gerente, e prenderam o Leo, sendo que apos a prisão dele, o Da Nike assumiu o local. Durante a investigação Joel foi preso e disse que armazenava drogas para Da Nike, e que não tinha muita informação, apenas que chamava Felipe e morava próximo ao Nova Tigrao, e com isso localizaram o réu. Outro interlocutor era Docinho, e a principio seria de uma mulher, mas depois ficou consignado que salvaria o nome dele desta forma, para despistar a policia sendo que foi identificado na operadora como William, e ele não tinha envolvimento criminal, entretanto, o mesmo numero registrado como docinho, também tinha o registro como Wellingrton no telefone de Alex, e passaram a investigar os parentescos de Willian, e identificaram que ele tinha um irmão de nome Wellington e que já teve problema com trafico, e em alguns momentos ele também era chamado de Gordão, e realmente ele e um individuo obeso. Prosseguindo a investigação, identificaram DG que junto com Docinho eram gerentes em Barueri e traziam para Aracariguama e deixavam com Lucas. Oficiaram a operadora que informou os dados cadastrais de Diego, e pesquisaram e não localizaram nada, mas ao ver o histórico de chamadas, duas questões apareceram, ligações com Cachaça e Cabeçudo e um dos telefones era de uma moça chamada Ingrid, que tinha uma filha de nome Lorena, e o pai seria Diego. Prosseguindo , Diego foi preso com Wellington em Barueri por roubo, e que ambos possuíam uma ligação. Tinha um numero de telefone de um individuo chamado Buda, e identificaram que este telefone não tinha nada do trafico, mas o nome da linha estava na pessoa de Graziele, a qual tinha um boletim de ocorrência contra um individuo chamado Jose Rodrigues que era o Buda, o qual já tinha sido preso por embriaguez na cidade, e já tinha sido abordado pela policia, mas como não havia nada a principio não pediram a prisão dele. Para identificar Lucas, quebraram o histórico de chamadas e avistaram muitas ligacões para um número, identificado como Fernando, que é usuário conhecido na cidade, e ele compareceu a delegacia, e questionado, ele disse que não era traficante, mas que teria comprado do gerente da biqueira, que seria o Lucas, e que ele morava na rua da Radio e que comprou uma geladeira da mãe do Lucas, e que chamava Katia. Conseguiram qualificar o Lucas, e o nome da mãe dele era Maria da Conceição e no facebook dele tinha a mãe dele, mas ela foi candidata a vereadora na ultima eleição, e usava o nome de Katinha do povo e no histórico das chamadas, havia ligações para o setor de saúde, onde a mãe dele trabalhava. Fernando voltou para pegar o celular que passou por perícia, e ele reconheceu o Lucas por fotografia. Solicitaram mandados de busca e prisão, e no momento dos cumprimentos, alguns foram presos, com exceção de Wellington e Diego que já estavam presos, e Jose Rodrigues foi levado a delegacia e confessou os fatos. Lucas também foi preso, e confessou os fatos. A mulher que cobra a divida no celular, não foi identificada, e Jose Luis, vulgo Buda deixou de comandar, e Lucas estava devendo para ele, e ambos quando presos confirmaram o trafico. A delegada pediu a prisão em virtude da confissão dele. No momento do flagrante do cachaça, Joyce estava na casa, mas foram apreendidos os celulares, onde mostrou envolvimento dela no trafico de drogas, mas no momento da prisão, ela tinha acabado de ter uma criança. Na operação de cumprimento de mandados não foi encontrada droga. Jose Luis, Diego e Wellington eram os distribuidores da droga para Aracariguama, o Lucas recebia e repassava para venderem, e também repassava para o Leo e Felipe para armazenarem e passarem para os vapores no Novo Tigrao. Não conhecia os reus, apenas

ouviu falar do Jose Rodrigues vulgo Buda. Conhecia Jose Bernardo e não tinha problema pessoal com ele. Não se recorda o momento em que pegaram o celular de Jose Luis Bernardo, e ele foi conduzido com o aparelho celular, mas se recorda que o réu desbloqueio o celular dele e autorizou o acesso, ate porque não tinham a senha do aparelho. Quem colhe os depoimentos e declarações é o escrivão, e acredita que não teve autorização por escrito, e não haveria acesso se o réu não tivesse entregue a senha ou a forma do desbloqueio. Lucas de forma informal disse que fazia parte da associação e do trafico, mas que teve prejuízo, e saiu, mas ainda devida para o Jose Rodrigues.

Luis Felipe cumpriu o mandado na casa do vulgo cachaça, e localizou uma porção de maconha em cima do armário, e na casa no Lucas ficou na porta, e outro policial fez a busca, e encontraram porções de drogas e ele foi preso na Ditin Industria Têxtil Ltda. Não se recorda da apreensão de celulares, e não participou da investigação.

Lucas Vinicius disse que cumpriu mandado na casa do Jose Luis Bernardo, e do Lucas. Na casa do Jose Luiz, foram entrando, e se depararam com o casal e com a criança, e foi dado ciência, e indagado a respeito de drogas, e armas, e ele disse que tinha porção de drogas que era para uso pessoal, e estava no armário. Depois se dirigiram a casa do Lucas, entraram e encontraram a mãe dele, e ela mostrou o quarto e encontraram certa quantidade de drogas, e ele estava trabalhando, e foi detido no labor. Não se recorda se foi apreendido celular ou dinheiro. Não se recorda se foi apreendido celular com Jose Luis Bernardo. Lucas disse que a droga era dele e não se recorda se estava separada ou era uma porção só.

Cleber Briamonte disse que efetuou a prisão de Joel, apos denuncia anônima, e ele chegou e foi questionado, e acabou admitindo que armazenava a droga para o rapaz conhecido como Da Nike, e mostrou a droga, e também pés de maconha. Ele chegou a mostrar a residência, próximo a casa dele, e foram arte o local mas estava fechado. Não soube dizer nada a respeito da investigação.

A principio vale mencionar que nenhuma restrição merecem os depoimentos dos policiais mormente quando suas declarações vêm corroboradas por outros elementos de prova e também quando não levantada qualquer suspeita fundada e demonstrada.

Nesse sentido: "não existe motivo algum a ensejar a desvalia do depoimento policial. Seria um contrassenso credenciar o Estado alguém a atuar em seu nome e, depois, negar-lhe crédito, quando, perante o mesmo Estado-Juiz, viesse relatar seus atos de ofício. Por isso, totalmente superada a tese do desprestígio do relato policial na moderna jurisprudência. O agente de segurança é testemunha como as demais. Submete-se a compromisso e terá seu depoimento avaliado no cotejo de todas as provas sem plus-valia, mas também sem preconceito." (TACRIM-SP JUTACRIM 30/221).

Com efeito, conforme amplamente decidido, "a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita" (STF, RTJ 68/54), entre outros arestos (RT 530/372, 411/266, 445/382 e RJTJESP-LEX 136/476). Ademais, seria um contrassenso o Estado credenciar pessoas para a função repressiva e depois lhe negar crédito quando dão conta de suas diligências (RT 417/94, 486/351, 771/565 e 772/682). Por isso, eventuais pequenas contradições entre os depoimentos prestados em Juízo, se comparados entre si e com os da fase administrativa, são naturais e reforçam a ausência de prévia combinação entre as pessoas ouvidas, ou qualquer sanha obstinada em falsa incriminação. Observa-se ainda que, "pequenas dissonâncias na prova oral não têm o condão de fazer esboroar o arcabouço probatório. O importante é constatar-se a concordância nos pontos essenciais, desprezando-se eventuais discrepâncias, em pontos secundários, que são fruto das imperfeições do psiquismo humano" (JUTACRIM 95/262).

"O depoimento do policial é tão válido como outro desde que insuspeito e capaz de

infundir, pelo seu conteúdo, incredibilidade. Por outro lado, nos termos do art. 202 do CPP, se toda pessoa pode ser testemunha, sem qualquer dúvida que os agentes podem testemunhar sobre o que viram e sentiram no cumprimento da missão. Se por/acaso outras pessoas havia no local da diligência, cumpre à defesa arrolá-las como testemunhas. Também pequenas divergências que não atingem a substância do fato não são suficientes para ilidir aprova" (RT574/401). "PROVA CRIMINAL - Testemunha - Hipótese de tóxico - Depoimento prestado por policial - Validade - Servidores que não estão impedidos de depor - Testemunhas, ademais, que não foram sequer contraditados em Juízo - Recurso provido. Os policiais militares, como qualquer outra pessoa, não estão impedidos de depor e seus testemunhos não podem e não devem ser, de modo algum, de forma apriorística, considerando suspeitos, apenas em decorrência da condição de policial, (relator Ângelo Galluci - Apelação Criminal nº 153.694-3-São Paulo-26.09.94)".

"DEPOIMENTO DE POLICIAIS. MEIO PROBATÓRIO VALIDO. - O depoimento de policiais pode servir de referência ao juiz na verificação da materialidade e autoria delitivas, podendo funcionar como meio probatório válido para fundamentar a condenação, mormente quando colhido em juízo, com a observância do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de prova". (STJ, 5.a Turma, HC 110869/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, v.u., j . 19.11.2.009; pub. DJe de 14.12.2.009).

(...) Tráfico de entorpecentes Materialidade e autoria comprovadas por depoimentos de policiais cujo conteúdo é harmônico com o conjunto probatório Validade No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário. Cálculo da Pena Tráfico de entorpecentes Imposição de privação de liberdade superior a quatro anos Inaplicabilidade da conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos por não atendimento ao requisito contido no inciso I, do art. 44, do CP. Na hipótese de ter sido imposta privação de liberdade superior a quatro anos, não se concebe sua conversão em pena restritiva de direitos, uma vez não ter sido atendido o quanto previsto no inciso I, do art. 44, do CP. (grifei) (Apelação nº 0001192- 93.2014.8.26.0028, Relator: GRASSI NETO, Comarca: Aparecida, data do julgamento: 14.05.2015; 8ª Câmara de Direito Criminal)

CONDENAÇÃO. TESTEMUNHO DOS POLICIAIS CORROBORADO COM DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS. POSSIBILIDADE. SÚMULA 83 DO STJ. A condenação do agravante foi alicerçada nos testemunhos dos policiais, meio de prova idôneo, e corroborada com os demais elementos constante nos autos, portanto, em conformidade com a jurisprudência pacífica deste Sodalício, situação que atrai o disposto na Súmula 83, do STJ, também aplicável ao recurso especial interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional. Agravo regimental improvido (AgRg no AREsp 615.878/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Julgado em 14/04/2015, DJe 22/04/2015). "São cansativas as alegações costumeiras contra a palavra dos policiais, como se eles sempre agissem fora da lei, em prejuízo de todos os acusados presos e autuados em flagrante. Mas, os depoimentos prestados por policiais não podem ser sumariamente desprezados apenas em razão de sua condição funcional, devendo ser aferida a sua credibilidade em função do exame atento do conjunto probatório existente nos autos..." (TJSP, Apelação Criminal 0002502-24.2008.8.26.006, Segunda Câmara Criminal, Relator Desembargador Antonio Luiz Pires Neto, Julgado em 13 de agosto de 2012).

Não trouxe o acusado qualquer prova ou elemento a contrariar a idoneidade dos depoimentos policiais.

Pelo contrario, os policiais sequer conheciam o réu, e não teriam motivos para

incrimina-lo injustamente.

Aponta-se que o réu confessou a participação na associação negando a atuação no trafico, no entanto, esta negativa se encontra isolada nos autos, ate porque a perícia do celular de Jose Luis Bernardo traz a estabilidade com Wellington e a venda de drogas.

Realmente a fls. 484/487 o réu conversa com Jose Luis Bernardo cobrando este a respeito do funcionamento da "loja" (biqueira), e que não poderia ficar parada, tanto que o co réu respondeu que a mesma é do lado de sua casa.

Na mesma conversa fazem a contabilidade das vendas, e do envolvimento de Lucas e Veinho, não deixando duvidas quanto a participação de Wellington que era o fornecedor das drogas como apontou a investigação ampla realizada pela policia civil.

As conversas telefônicas e a investigação policial detalhada e minuciosa conforme relatório trazido aos autos e reiterado em depoimento judicial trouxeram a certeza do envolvimento do acusado, e que seria o fornecedor da droga revendida pelos demais nos pontos de venda na cidade de Aracariguama.

Pontua-se ainda que por três vezes foram apreendidas drogas da associação, a primeira junto com Jose Bernardo, posteriormente com Joel, e por fim quando do cumprimento de mandado de busca e apreensão, e com Jose Bernardo solto, mais drogas foram encontradas em sua residência o que denota que realmente estava dedicado a traficância.

Não se pode deixar de considerar que as drogas apreendidas em três ocasiões diversas pertenciam a associação, sendo que o fato de alguns dos envolvidos serem usuários não descaracteriza o delito.

Realmente não é caso desclassificação mas sim de trafico de drogas com participação dos envolvidos e desenvolvendo funções específicas como apontado pela investigação policial.

Alias o amplo e detalhado relatório de investigação policial que se encontra a fls 04/48 acabou por ser comprovado com as provas produzidas na fase do contraditório que soma-se aos laudos periciais e os depoimentos dos policiais responsáveis, alem da efetiva apreensão de drogas em três oportunidades e que acabam por corroborar a confissão parcial de Wellington.

Em suma, os depoimentos colhidos, à luz do contraditório e as demais provas acostadas aos autos, somadas a efetiva apreensão de droga, evidenciam a realidade do tráfico exercido pelo réu em associação com os demais.

Vale citar: "Adquirir, guardar, vender, ou trazer consigo, sem autorização legal ou regulamentar, substância entorpecente, são condutas comuns aos delitos de tráfico ilícito e uso indevido, do que resulta, pelo princípio da exclusão, quando não se tratar de uso indevido, reconhecer o narcotráfico. Caracteriza o delito de tráfico ilícito de substância entorpecente trazer consigo, sem autorização legal ou regulamentar, maconha e cloridrato de cocaína, em doses unitárias, de pequenos embrulhos, embalagem usual do varejo das drogas" (TJRJ - AC 1.185/93 - Rel. Enéas Machado Cotta - TDTJRJ 23/288).

A lei pune o tráfico ilícito de entorpecente em qualquer de suas condutas, típicas e exclusivas. Em tema de entorpecente, a conduta de guardar, ter em depósito, trazer consigo para fins de tráfico, sem autorização legal ou regulamentar, a droga proibida, basta para integrar a figura criminosa do tráfico ilícito. Vender, em tema de entorpecente, é uma das condutas típicas, e não "conditio sine qua non" de

delito de tráfico ilícito. Nesse sentido: "Apelação - Tráfico de entorpecentes - Materialidade e autoria devidamente demonstradas nos autos, pela prova documental e oral - Conjunto probatório suficiente à condenação - Pleito visando a desclassificação para o delito de porte de drogas - Impossibilidade - A diversidade, a forma de acondicionamento da droga, sua quantidade, assim como as circunstâncias da apreensão, demonstram, à evidência, que o entorpecente se destinava ao tráfico - Pena e regime corretamente fixados - Sentença mantida - Apelo improvido. (Apelação nº 0005711-21.2009.8.26.0050, TJ/SP, 16 Câmara de Direito Criminal, negaram provimento, v.u, data julgamento 01/03/2011, relator Des. Borges Pereira)

"Importante ressaltar, ainda, que para a configuração do crime de narcotráfico, sequer é exigido qualquer ato de mercancia, bastando que o agente traga consigo, tenha em depósito ou guarde a substância proibida, não sendo necessária a tradição para consumação do delito" (RJTJSP - Apelação Criminal 0000272-15.2018.8.26.0470 - Des. Marco Antônio Cogan Data do julgamento: 06/02/2020).

"A inversão do ônus da prova, uma vez que o trabalho acusatório demonstrou suficientes indícios de autoria, além de prova cabal da materialidade do crime, incumbindo, pois, às defesas indicarem fatos que afastasse, inequivocamente, os seguros indicativos da participação das acusadas no crime. "Para a formação de um juízo de certeza razoável sobre o comércio de entorpecentes, não é necessária prova efetiva do tráfico. O conjunto de indícios e elementos que cercam o agente infrator podem fornecer o material de convencimento da traficância. Inexige-se, portanto, prova flagrancial do comércio ilícito, bastando, como já dito, elementos indiciários, como 'confissão extrajudicial, a quantidade e qualidade do material apreendido, a conduta e os antecedentes do agente, bem como as circunstâncias da prisão' (art. 37, LT), ser substância oriunda de área e rota de comércio ilícito etc. Erigir-se, como regra, a necessidade de prova direta da finalidade comercial da substância entorpecente em poder do acusado, para fazer incidir o art. 12, por um lado é inviabilizar o combate ao tráfico e ao mesmo tempo dar ensejo à disseminação do comércio ilícito. Além de sob o ponto de vista jurídico constituir-se numa teratologia." (RODRIGUES, João Gaspar. Tóxicos: Abordagem crítica da Lei nº 6.368/76. Campinas: Bookseller, 2001.p. 157).

"APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO-DE ENTORPECENTES - ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS - RESPEITO AO PRINCÍPIO DO IN DÚBIO PRO REO - PRETENSÃO IMPROCEDENTE - DEPOIMENTO POLICIAL CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA - CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE - RECURSO IMPROVIDO. Não há falar em absolvição com base na negativa de autoria isolada nos autos, quando os demais elementos de prova, como depoimento prestado por policial dão suporte à condenação do réu. O testemunho prestado por policial é válido e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se traga aos autos, porquanto são revestidos de presunção de veracidade até que haja prova em contrário. (Apelação Criminal - Reclusão - N. 2010.002225-8 - Três Lagoas - Relator - Des. Claudionor Miguel A. Duarte - Julgamento: 8/3/2010)

Apelação - Tráfico DE ENTORPECENTES - CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA - Interceptação Telefônica PROVIMENTO PARCIAL. Mantém-se a condenação do acusado pelo tráfico de entorpecentes quando devidamente caracterizadas a autoria, a materialidade e tipicidade. [...]. O crime de tráfico de entorpecentes é de natureza múltipla, caracterizando-se quando o agente pratica um ou mais dos núcleos do tipo previsto no art.33 da Lei 11.343/06. (AC nº 1.0384.07.053086-8/001 - Rei. WALTER PINTO DA ROCHA - Data da Publicação: 04/04/2008). É certo que para a caracterização do tráfico de entorpecentes não é indispensável a prova do ato de comércio, podendo ser ele deduzido de elementos carreados, como as circunstâncias da prisão, a quantidade do entorpecente, o local da infração, etc. Nesse sentido, sobre o valor probatório dos indícios, cita-se a lição de Julio Fabrinini Mirabete, constante no acórdão do ilustre Relator Borges Pereira(Apelação nº 0005711-21.2009.8.26.0050, TJ/SP, 16 Câmara de Direito Criminal, negaram provimento, v.u,

data julgamento 01/03/2011), a saber:(...) tanto mais forte o indício quanto mais íntima sua relação com o fato, não havendo princípios inflexíveis sobre o valor da prova indiciária no processo (...) diante do sistema da livre convicção do juiz, encampado pelo Código, a prova indiciária, também chamada circunstancial, tem o mesmo valor das provas diretas, como se atesta na exposição de motivos, em que se afirma não haver hierarquia de provas por não existir necessariamente maior ou menor prestígio de uma com relação a outra. Assim, indícios múltiplos, concatenados e impregnados de elementos positivos de credibilidade são suficientes para dar base a uma decisão condenatória, máxime quando excluem qualquer hipótese favorável ao acusado, (in Código Penal Interpretado - Ed. Atlas - SP -1999 - pág. 532). (citado no corpo do acórdão da apelação 0005711-21.2009.8.26.0050,TJ/SP, 16 Câmara de Direito Criminal, negaram provimento, v.u, data julgamento 01/03/2011, relator Dês. Borges Pereira)

No tocante a associação também não se tem duvidas do envolvimento do réu com os demais sendo que juntamente com Diego fornecia a droga para Jose Luis Bernardo e Jose Luis Rodrigues, tanto que faz a contabilidade e cobrança de funcionamento da biqueira com o primeiro.

Restou demonstrado o vínculo associativo, a reunião de vontades para um fim comum.

“de vez que o que importa é a união de propósitos, o 'animus associativo' que ficou bem caracterizado pelo conjunto das provas. Isso, por si só, configura o crime” (TJESP, Apelação Criminal nº. 0323454- 87.2010.8.26.0000, Relator Desembargador ROBERTO MIDOLLA,julgado 16-02-2.012).

“Para a existência de crime autônomo de associação é mister: a) duas ou mais pessoas; b) acordo dos parceiros; c) vínculo associativo; d) finalidade de traficar tóxicos” (JTACrimSP 57/280), de forma reiterada ou não (RJTJESP 105/444).

“ Não obstante a materialidade do crime de trafico pressuponha apreensão da droga, o mesmo não ocorre em relação ao delito de associação para o trafico, que, por ser de natureza , sua materialidade pode advir de outros elementos de provas como por exemplo, interceptações telefônicas.” (STJ, HC 148480 – BA, 6 T., rel.Og Fernandes, 06/05/2010, v.u).

Realmente existia o vínculo entre as partes, não se tratando de mera eventualidade, mas sim habitualidade, estabilidade.

De fato, o relatório policial e a investigação detalhada em juízo pelo investigador não deixaram dúvidas da estabilidade da associação e a divisão de funções dos envolvidos, explicando que Diego e Wellington eram os distribuidores da droga para Aracariguama, entregando para Jose Luis e que Lucas recebia e repassava para outros venderem, e também repassava para o Felipe o qual também armazenava e passava para os vapores no Novo Tigrao, além da participação de Jose Rodrigues que era responsável por alguns pontos de venda abastecidos pela associação.

Portanto, restou comprovado que o reu estava associado, com divisão de tarefas e de maneira estável, o que leva a procedência da acusação.

Desta forma a procedência da ação é de rigor, condenando o reu pelos traficos e associação nos moldes pretendidos pela denuncia.

Passo a dosimetria da pena.

Atento ao disposto no artigo 42 da Lei 11343/06 e art.59 do Código Penal, verifico para todos os reus que a quantidade de droga era significativa, e renderia lucro considerável, e com grande valor econômico o que mostra a desvalia da conduta, sendo que este fator, pode ser usado na fixação da pena base para todos os reus.

Nesse sentido: "HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA BASE. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. ART. 42 DA LEI 11.343/06. EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL AUSENTE. 1. Em se tratando de crime de tráfico de drogas, como ocorre na espécie, na fixação das penas, deve-se considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do CP, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, consoante o disposto no art. 42 da Lei 11.343/06. 2. Verificado que foi levada especialmente em consideração a natureza e a quantidade da substância encontrada - 693 g (seiscentos e noventa e três gramas) de cocaína -, não há que se falar em constrangimento ilegal quando a sanção básica foi fixada apenas seis meses acima do mínimo legalmente previsto, vez que apontados fundamentos concretos a justificar maior reprimenda. Ordem denegada" (STJ - HC nº 231882/SP rel. Min. Jorge Mussi j. 20/06/2012). "A dosimetria da pena, além de não admitir soluções arbitrárias e voluntaristas, supõe, como pressuposto de legitimidade, adequada fundamentação racional, revestida dos predicados de logicidade, harmonia e proporcionalidade com os dados empíricos em que se deve basear. 2. Idônea a exasperação da pena-base com fundamento na natureza das substâncias traficadas, consoante preconiza o art. 42 da Lei 11.343/2006 c/c art. 59 do Código Penal. 3. A avaliação do quantum de atenuação da pena, à míngua de previsão legislativa dos parâmetros a serem considerados, sujeita-se ao livre convencimento motivado do julgador, observado o limite máximo de redução, as circunstâncias do caso e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade" (STF - RHC 129951 / PR Rel. Min. Teori Zavascki Segunda Turma DJe 08/10/2015.). Assim, reconhecendo este fator, a apontar a culpabilidade acima da média somado a condenação recente a indicar a má conduta social fixo a pena em fixação da pena em 1/6 acima do mínimo para cada delito. Ausentes agravantes já que não é possível considerar a questão da pandemia que não tem relação causal para facilitar a prática do delito. Reconheço a confissão do réu apenas no tocante a associação reduzindo a pena desta ao mínimo local, mantendo a pena do tráfico. Ausentes causas de aumento de pena e não se aplica o redutor, já que o acusado está sendo condenado pela associação, o que denota dedicação exclusiva para a venda de drogas, permanecendo a reprimenda em 05 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583 dias-multa pelo tráfico e 03 anos de reclusão e pagamento de 700 dias-multa pela associação. Ainda o réu cometeu três tráficos de modo que considero o crime continuado elevando a reprimenda em 1/5, totalizando 07 anos de reclusão e pagamento de 1749 dias-multa já que para os dias-multa incide o disposto no artigo 72 do Código Penal. Reconheço o concurso material e somo as penas totalizando 10 anos de reclusão e pagamento de 2565 dias-multa.

Fixo a míngua de outro elemento o dia -multa no mínimo legal.

Ainda deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos para o réu, por não ser permitido pela lei 11343/06, e por partilhar do entendimento da inviabilidade do acolhimento de tal benefício em relação ao crime de tráfico ilícito de entorpecente. Realmente o delito de tráfico envolve o que há de pior no ser humano em relação ao seu semelhante, lucrando-se e aproveitando-se da fraqueza humana, destruindo dependentes e familiares. Na verdade a droga se constituiu no principal mote da violência, sustentando toda uma cadeia criminoso, com lucro fácil, não sendo possível, premiar o traficante que tanto mal causa a terceiros com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Pontua-se ainda que as penas superam o limite legal.

Saliento que não seria possível a aplicação da substituição tendo em vista a vedação do inciso III do artigo 44 do Código Penal, já que possuem circunstância judicial negativa, além do total de pena aplicado a espécie. Incabível a suspensão condicional da pena, pelas mesmas razões.

"RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO LEGAL EXPRESSA. RECURSO PROVIDO. 1. Não tem direito à

suspensão condicional da pena quem é condenado por crime de tráfico de drogas, positivado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, por expressa vedação do art. 44, caput, dessa lei. (...)" (STJ, REsp 1373032/DF, 6ª Turma, Min. Rogério Schietti Cruz, jg. 17/12/2015, DJe 11/03/2016)

Levando-se em consideração a quantidade de drogas, e o alcance significativo de usuários, a indicar uma maior reprovabilidade da conduta, somado as circunstâncias judiciais negativas já reconhecidas do réu e a pena aplicada fixo o regime inicial fechado para início de cumprimento de pena.

Mesmo considerando o tempo da prisão ainda não foi atingido o limite suficiente para alteração do regime.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado constante na denúncia, para CONDENAR como incurso no artigo 33 caput da lei 11343/06 por três vezes na forma do artigo 71 do Código Penal e artigo 35 da lei 11343/06 em concurso material, o réu WELLINGTON FERREIRA BORGES a pena privativa de liberdade de 10 (dez) anos de reclusão em regime inicial fechado além do pagamento de 2565 (dois mil quinhentos e sessenta e cinco) dias-multa com valor unitário que consiste em um trigésimo do salário mínimo mensal vigente no dia dos fatos (art. 49, § 1º, do mesmo Código), a partir do qual será atualizado, em conformidade com o art. 49, § 2º, primeira parte, do aludido Estatuto Penal (cfr. SEBASTIÃO DA SILVA PINTO em RT 645/255-262; TACRIM em RT 682/335, 782/614, JUTACRIM 95/45; STJ em RE 41.438-5-SP, 5ª T., Rel. Min. ASSIS TOLEDO, em D.J.U. 17/10/94, pág. 27.906; STJ - Embargos de Divergência em Recurso Especial nº 91.003-RS - 3ª S - Rel. Min. Gilson Dipp - J. 13.12.99 - DJU 21.02.2000; STJ, RE 22.497/8-SP, 5ª T., Rel. Min. José Dantas, DJU 13.10.1992, p. 17.700 etc).

Custas pelo acusado nos termos da lei, restando suspensa a exigibilidade diante da Defesa dativa a ele ofertada.

Não verifico condição a alterar a prisão do réu que já se encontram preso, que permanece hígida, contemporânea e necessária, ate porque em liberdade se envolveu em crime grave com condenação, o que mostra que a liberdade é um risco a ordem publica, ademais, estava envolvido em associação organizada e que atuava na venda de drogas, fomentando a violência e o caos urbano, o que mostra a habitualidade delituosa e que afeta a ordem publica, fomentando a violência e a guerra urbana o que mostra o risco a ordem publica. A questão de possuir filho pequeno, não leva a liberdade, ate porque não demonstrou que seria o principal provedor, não existindo qualquer elemento a indicar desamparo. Assim, por todos os lados não se constata alteração das condições, estando presentes os requisitos da prisão, o que leva ao indeferimento do recurso em liberdade. Expeça-se novo mandado de prisão em desfavor ao réu.

Nesse sentido: "HABEAS CORPUS alegação de falta de fundamentação da r. sentença que indeferiu o direito de recorrer em liberdade, tendo se baseado tão somente na gravidade concreta do crime inoccorrência. HABEAS CORPUS presença do fumus comissi delicti no auto de apreensão e prova oral que indica a subtração mediante violência e grave ameaça, indicando o paciente como autor presença do periculum libertatis pelo fato do paciente não ter vínculo com o distrito da culpa; praticar o crime com alta reprovabilidade e periculosidade; não haver prova de que exerce atividade lícita prisão preventiva que não ofende o princípio da presunção de inocência fato de ser primário e sem antecedentes, bem como possuindo residência fixa, não vedam a possibilidade da prisão cautelar. HABEAS CORPUS desproporcionalidade da medida remédio heroico que não se presta a exercício de futurologia. HABEAS CORPUS pandemia COVID-19 paciente que não compõe grupo de risco efetivo isolamento social - indefere-se o processamento. Observa-se que o paciente praticou crime de roubo majorado, com emprego de grave ameaça à pessoa. A prática de crimes com violência ou grave ameaça contra a pessoa geram desassossego e intranquilidade popular. A circunstância de alguém praticar crime desta espécie e ser solto em seguida causará

descrédito na Justiça, além de estimular à prática de novos crimes análogos, bem como levará a população a buscar resolver os problemas de segurança por outros métodos, como fazer justiça com as próprias mãos. Desta forma, necessária a custódia do requerente para garantia da ordem pública para estes casos, a menos que ocorra excepcionalmente prova em contrário, não existente nos autos. (Habeas Corpus Criminal nº 2132867-25.2020.8.26.0000, TJSP, relator Desembargador Lauro Mens de Mello, 30/06/2020). "Agravamento regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º). Processual Penal. Prisão preventiva (CPP, art. 312). Falta de fundamentação para justificar a medida extrema. Não ocorrência. Garantia da ordem pública. Gravidade em concreto da conduta e real periculosidade do agravante. Risco real de reiteração delitiva. Fuga do distrito da culpa. Custódia preventiva devidamente fundamentada. Regimental não provido. 1. Mostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão do seu modus operandi, como também pelo risco real da reiteração delitiva. 2. Consoante o entendimento do Supremo Tribunal Federal, "a evasão após a prática delitiva é fundamento idôneo para a segregação cautelar para resguardar a aplicação da lei penal" (HC nº 90.162/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 29/6/07). 3. Agravamento regimental ao qual se nega provimento" (2 STF HC 127578 AgR/SP rel. Dias Toffoli j. 25.08.2015); "A prisão cautelar justificada no resguardo da ordem pública visa prevenir a reprodução de fatos criminosos e acautelar o meio social, retirando do convívio da comunidade o indivíduo que diante do modus operandi ou da habitualidade de sua conduta demonstra ser dotado de periculosidade". "A prisão preventiva mostra-se necessária para a garantia da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do paciente, evidenciada por sua personalidade delitiva, já que foi condenado por roubo e estelionato (reincidência), responde por furto e cometeu o delito em questão quando estava em livramento condicional" (STJ HC 246855 / MG rel. Min. Marilza Maynard j. 21.02.2013) "A prisão cautelar se mostra suficientemente motivada para a preservação da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do paciente, verificada pelo modus operandi mediante o qual foi praticado o delito. Precedentes. II A possibilidade concreta de fuga também mostra-se apta a embasar a segregação cautelar para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes. III Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que, permanecendo os fundamentos da custódia cautelar, revela-se um contrassenso conferir ao réu, que foi mantido custodiado durante a instrução, o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação. Precedentes. IV - Ordem denegada" (0 STF HC 114536/MG Rel. Min. Ricardo Lewandowski DJU 05.12.2012.).

Autorizo assegurada a contraprova e desde que não providenciado, a incineração da droga apreendida independente do trânsito em julgado.

Oportunamente, após o trânsito, providencie-se o necessário para o efetivo cumprimento da sanção imposta, remetendo-se após ao arquivo com as cautelas de praxe, comunicando e oficiando ao IRGD e a Justiça Eleitoral e expedindo a certidão de honorários do Defensor nomeado.

Sao Roque, 05 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA